

1500162-96.2022.8.26.0632

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcela Corrêa Dias de Souza

Comarca: Urânia

Foro: Foro de Urânia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Estado de São Paulo, se encontrem na mesma situação (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses, em regime fechado), fixar o regime aberto.

21.3. Em relação aos presos condenados, pelo delito de tráfico privilegiado, a penas menores do que 4 anos de reclusão - salvo os casos do item anterior - determinar que os respectivos juízes das Varas de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urânia

Foro de Urânia

Vara Única

Avenida Barão do Rio Branco, 818, Urania-SP - cep 15760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500162-96.2022.8.26.0632 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500162-96.2022.8.26.0632

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162532/2022 - 01º D.P. JALES, 25571621 - 01º D.P. JALES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUAN MANOEL CARLOS CELESTINO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcela Corrêa Dias de Souza

Vistos.

JUAN MANOEL CARLOS CELESTINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos assim narrados na denúncia:

"Consta do incluso procedimento que, no dia 14 de junho de 2022, por volta de 22:00 horas, na Rodovia Euclides da Cunha, Km 599, no município de Santa Salete, nesta Comarca de Urânia, o denunciado JUAN MANUEL CARLOS CELESTINO DOS SANTOS, qualificado às fls. 05 e 08/09, trazia consigo e transportava, para fins de traficância, 01 (uma) porção de "cocaína", com peso líquido de 145,81 gramas, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 23/26 e laudo toxicológico de fls. 88/90.

Segundo o apurado, o denunciado JUAN MANUEL CARLOS CELESTINO DOS SANTOS conduzia a motocicleta Yamaha/YBR 150 Factor ED, placa DOS2260 - Santa Fé do Sul, pela Rodovia Euclides da Cunha, sentido Jales/Santa Fé do Sul, em alta velocidade e com outro indivíduo na garupa.

Diante disso, policiais militares rodoviários saíram no seu encalço e, durante a tentativa de fuga, JUAN dispensou uma sacola plástica, contendo 01 (uma) porção de "cocaína".

Em poder do denunciado e do ocupante da motocicleta foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares, além de R\$ 20,00 em dinheiro.

A natureza e quantidade da droga apreendida (suficiente para a confecção de inúmeras porções para consumo pessoal), assim como as demais circunstâncias da prisão em flagrante, em especial, a condução da motocicleta em alta velocidade e a tentativa de fuga ao perceber a presença dos policiais, indicam que a substância se destinava à comercialização e ao consumo de terceiros".

A prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva (fls. 52/59).

A denúncia foi oferecida em 24 de junho de 2022, oportunidade em que o Ministério Público promoveu o arquivamento em relação ao investigado Kadmo Matheus de Paulo (fls. 98/102).

Foi determinada a notificação do acusado, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 11.343/2006, bem como foi determinado o arquivamento dos autos do inquérito policial em relação ao investigado Kadmo Matheus de Paula (fls. 104/107).

O acusado foi notificado (fls. 122) e apresentou resposta à acusação (fls. 138/165).

O Ministério Público manifestou-se pelo recebimento da denúncia e manutenção da prisão preventiva (fls. 168/170).

A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2022 (fls. 172/175), e, na mesma oportunidade, foi mantida a prisão preventiva.

Foi designada audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fls. 198/201).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como o acusado foi interrogado (fls. 246/247).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos moldes preconizados na denúncia. Sustentou que as provas são firmes e suficientes a embasar o decreto condenatório. Disse não ser cabível a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Pugnou pela procedência da ação penal e a decretação do perdimento dos bens apreendidos (fls. 250/263).

A defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, alegando que a quantidade de drogas não é suficiente para aferir, por si só, o grau de envolvimento com a criminalidade organizada ou dedicação às atividades delituosas. Salientou que o acusado é

primário e sem antecedentes, estando ausentes provas de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa. Mencionou que as testemunhas arroladas pela defesa garantem que o acusado é pessoa honesta e trabalhadora. Salientou que o acusado desempenhou função de "mula". Pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal e ser possível a substituição por restritiva de direito, bem como cabível a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto. Requereu o direito de o acusado recorrer em liberdade, bem como a restituição do veículo apreendido para o pai do acusado. Juntou documentos (fls. 294/311).

É, em síntese, o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público, visando à condenação do acusado Juan Manoel Carlos Celestino dos Santos como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo de constatação (fls. 23/26) e exame toxicológico definitivo (fls. 88/91), fotografias (fls. 27/29), bem como pelas demais provas produzidas no decorrer da instrução processual.

A autoria também é incontroversa.

O acusado Juan Manoel Carlos Celestino dos Santos, ao ser interrogado em solo policial, a fls. 05, disse que: "Que não possui advogado constituído e, neste ato, dispensa a presença de um para seu interrogatório. Deseja que sua genitora seja avisada de sua prisão, o que será providenciado. Quanto aos fatos, confessa-os. Nesta data, trabalhava como pintor em uma casa próxima à praça Bela Vista, na cidade de Santa Fé do Sul, quando um rapaz alto e moreno, que sabe se chamar VINICIUS, ali compareceu e perguntou se a motocicleta era sua. Disse a ele que sim, então ele perguntou se o interrogado não faria um "frete" para ele, vindo até esta cidade para buscar o entorpecente apreendido. O interrogado receberia mil reais pelo serviço e, por alegar estar com dívidas, aceitou a oferta. Chamou seu amigo KADMO para vir junto, mas não lhe disse o que iriam fazer, falou apenas que iriam "dar um rolê". Nesta cidade, foi até uma praça próxima à escola EUPHLY JALES e um rapaz em um veículo Vw/Gol lhe entregou o pacote que colocou no bolso e voltava para Santa Fé do Sul, era o interrogado quem dirigia o auto. O entorpecente estava em seu bolso. Reafirma que KADMO não tinha ciência do que faria nesta cidade. Ao perceber a aproximação da viatura, retirou o entorpecente do bolso e o arremessou. Não possui passagem criminal anterior. Alega que foi a primeira vez que aceitou realizar tal serviço, só o fez porque está com dívidas. Não conhece a pessoa que lhe entregou o entorpecente e não sabe dizer maiores detalhes sobre ele. Sabe que VINICIUS residiria próximo à praça da Bela Vista, mas não sabe dizer maiores dados sobre ele. VINICIUS lhe deu setenta reais para abastecer sua motocicleta e o restante do dinheiro receberia na entrega. Os vinte reais apreendidos são troco do abastecimento".

Em juízo, disse que não foi preso ou processado criminalmente. É usuário de maconha. No dia dos fatos, foi até a cidade de Jales para buscar a cocaína para o Vinicius. Estava trabalhando e chegou um rapaz e questionou se a motocicleta era dele e perguntou se buscaria cocaína na cidade de Jales e "daria uma notinha em dinheiro". Relatou que estava com dívida e não pensou duas vezes em ir buscar a droga. Mencionou que essa pessoa (Vinicius) viu que ele estava trabalhando na obra e pediu para fazer a "corrida" para ele. Disse que nunca tinha visto Vinicius. Ressaltou que Vinicius percebeu que ele estava fumando maconha na hora do almoço na obra. Não chegou a receber pelo transporte, pois receberia assim que chegasse na praça "Bela Vista". Contou que se arriscou em fazer o transporte mesmo sem receber.

Narrou que não tentou empreender fuga, mas jogou a sacola com o entorpecente. Foi a primeira vez que fez esse transporte. Está arrependido e pretende parar de fazer uso de droga. A motocicleta era do seu pai. Relatou que seu pai não imaginava o que ele estava fazendo, pois acreditava que estava indo com a moto na academia.

A testemunha Pedro Henrique Cotrim, na fase extrajudicial, a fls. 02, disse que: "Que é policial militar rodoviário, nesta data, se encontravam em patrulhamento de rotina, sendo que passavam pelo pátio do posto Paulistão, próximo à cidade de Urânia. Em dado momento, avistaram uma motocicleta passar em alta velocidade, sendo que foram ao seu encalço. Tratava-se de uma Yamaha 150 Factor, com dois ocupantes. Os sinais de parada não foram respeitados e, perto do trevo da cidade de Santa Salete, viram que algo fora arremessado na via. Abordaram a motocicleta cerca de cem metros a frente, com o piloto JOAN havia o valor de vinte reais. Com o garupa CADMO nada de ilícito fora apreendido. Ao retornarem pela via, localizaram uma sacola azul com substância aparentando ser cocaína. Cada um trazia consigo um aparelho celular, também apreendidos. Apresentaram ambos nesta unidade de plantão, juntamente com o entorpecente e o veículo".

Em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, realizavam patrulhamento no "Posto Paulistão" e avistaram uma motocicleta passando com dois rapazes, em alta velocidade. Contou que decidiram ir atrás para realizar a abordagem, mas houve o arremesso de uma sacola plástica. Mencionou que realizaram a abordagem e, em revista pessoal, nada encontraram. Confirmou que localizaram o objeto que aparentava ser uma porção de "cocaína". Disse que o acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia. Afirmou que Juan assumiu que a droga era dele, dizendo que trabalhava em uma obra e que um terceiro, de nome Vinicius, o havia contratado para buscar a droga na cidade de Jales, ganhando o valor de R\$ 1.000,00. Não sabe se havia batedor, mas, no momento da abordagem, ninguém buscou facilitar para o acusado sair do local. O acusado não passou maiores informações a respeito do Vinicius.

A testemunha Rodrigo do Espírito Santo, policial militar, na fase extrajudicial, a fls. 03, disse que: "Que é policial militar rodoviário e, nesta data, se encontravam em patrulhamento de rotina, sendo que estavam no pátio do posto Paulistão, perto da cidade de Urânia, quando avistaram uma motocicleta YAMAHA 150 Factor passar em alta velocidade pela pista, com dois ocupantes. Dessa forma, foram ao encalço e passaram a dar sinal de luz, os quais não foram obedecidos de imediato. Perto do trevo da cidade de Santa Salete viram que algo fora arremessado na via. Abordaram a motocicleta cerca de cem metros a frente, com o piloto JUAN havia o valor de vinte reais e um aparelho celular. Com o garupa KADMO havia apenas um aparelho celular. Ao retornarem pela via, localizaram uma sacola azul com substância aparentando ser cocaína. Apresentaram ambos nesta unidade de plantão, juntamente com a motocicleta e o entorpecente".

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento no pátio de um posto de combustível às margens da rodovia. Visualizaram a motocicleta passando em alta velocidade, com dois ocupantes. Resolveram abordar e, após acionarem sinal luminoso, os indivíduos demoraram um tempo até parar o veículo. Visualizaram que foi dispensado algum objeto por um deles. Abordaram o acusado e retornaram ao local e localizaram o entorpecente. Em conversa informal, o Juan disse que havia sido contratado por terceiro para buscar o entorpecente na cidade de Jales, recebendo a quantia de R\$ 1.000,00. O acusado apenas disse que o nome desse terceiro seria Vinicius. Mencionou que o acusado não é conhecido nos meios policiais.

A testemunha arrolada pela defesa, Marinalva Xavier da Silva, ouvida apenas em juízo, disse que o acusado é seu vizinho. Nunca viu movimentação de pessoas na residência do acusado. O acusado é pessoa trabalhadora e ajuda a família. A motocicleta é do pai do acusado, que é mototaxista. Não sabe indicar qual a moto que o pai do acusado utiliza para trabalhar. Não teve contato com o acusado no dia

dos fatos.

A testemunha arrolada pela defesa, Regivan Adriano Martins, ouvida apenas em juízo, disse que conhece o acusado, pois trabalhava com ele. Disse que o acusado é bom funcionário. O acusado tinha uma dívida com ele, porque havia batido o seu carro. Nunca presenciou o acusado vendendo entorpecentes. O acusado é pessoa honesta e trabalhadora.

A testemunha arrolada pela defesa, Gilberto Faidiga, ouvida apenas em juízo, disse que conhece o acusado desde quando ele nasceu. Disse que a família e o acusado são frequentadores da Igreja Católica. Tinha conhecimento de que o acusado estava fazendo uso de entorpecentes e já conversou com o acusado sobre o assunto, pois estava preocupado. O acusado disse que "o dia que quisesse, pararia com isso". A família do acusado é de pessoas trabalhadoras. O pai é taxista e a mãe é servidora pública municipal. Ficaram estado de choque com a prisão do acusado em razão da educação que os pais deram ao acusado. A motocicleta apreendida é a ferramenta de trabalho do pai. A motocicleta do pai do acusado é uma Yamaha Y-150. Tinha conhecimento de que o acusado fazia uso de maconha. Narrou que o acusado afirmou que aprendeu a fazer uso de entorpecente no uso de maconha. Conhece a praça Bela Vista e não conhece algum Vinicius que moraria perto.

A testemunha arrolada pela defesa, João Pedro Meira dos Santos, ouvida apenas em juízo, disse que é primo do acusado. O acusado já trabalhou com ele. Sabe que o acusado faz uso de maconha, mas não no horário de serviço. Nunca presenciou o acusado vendendo entorpecente.

Eis as provas coligidas aos autos.

No caso sub judice, as provas amealhadas aos autos trazem tranquilidade necessária ao édito condenatório do acusado nas sanções do crime de tráfico de drogas.

Com efeito, conforme se verifica pelo auto de exibição e apreensão e laudo pericial, restou evidenciado que o acusado trazia consigo e transportava, para fins de traficância, 01 (uma) porção de "cocaína", com peso líquido de 145,81 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os policiais militares rodoviários afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina e, em dado momento, avistaram uma motocicleta passar pela rodovia em alta velocidade, com dois ocupantes. Disseram que deram sinal de parada, mas sem que fosse respeitado.

Mencionaram que, perto do trevo de Santa Salete, viram que algo foi arremessado na rodovia. Relataram que conseguiram fazer a abordagem da motocicleta e, com o acusado, foi localizada a quantia de R\$ 20,00. Por fim, disseram que, ao retornar pela via, localizaram a sacola contendo o entorpecente apreendido.

Como se sabe, os depoimentos dos policiais são merecedores de confiança, como de resto qualquer outro depoimento, até que se prove o contrário. E, no contexto probatório apresentado nos autos, nada há para lhes retirar o crédito de que são merecedores.

HUGO NIGRO MAZZILLI, de forma lapidar, assim se expressou sobre o testemunho de policiais:

Não merece o depoimento dos policiais uma eiva abstrata e genérica de suspeição. Se o Estado encarrega seus agentes do grave munus de defender a coletividade contra o crime, se os arma, se lhes dá poder de polícia, se lhes atribui a investigação de crimes e até o direito de prender pessoas e apreender bens, seria rematado contra-senso recusar-lhes a priori qualquer crédito ao seu depoimento, apenas porque são policiais. Ora, seu testemunho há de ser aferido no contexto instrutório, no seu

todo, e se, longe de desmentido pela instrução, for com esta coerente, razão não há para recusá-lo (RT, 417:94). Ou mais, seria indesculpável dislate obrigar os policiais a combaterem o crime e, depois, negar validade a seu subsequente depoimento. (in QUESTÕES CRIMINAIS CONTROVERTIDAS, Saraiva, 1999, pág. 776).

Nesse sentido, também se posicionam os tribunais:

Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição. (RT.614/2756). No mesmo sentido, TJMG: RT. 444/406, 604/407; TJRJ: RT.595/423 etc.

Cabe ressaltar que, em nenhum momento, seja na fase policial, no momento da prisão em flagrante, ou em juízo, na oportunidade em que foi interrogado, o acusado trouxe aos autos qualquer elemento probatório hábil que pudesse ser utilizado para desmerecer os testemunhos prestados pelos policiais militares ouvidos em juízo.

Por seu turno, o acusado Juan Manuel confessou a prática delitiva em solo policial e em juízo, afirmando que teria sido contratado por terceiro para fazer o transporte da droga, mediante o pagamento do valor de mil reais.

Cabe registrar que houve a apreensão de quantidade relevante de entorpecente, suficiente para confecção de diversas porções individuais, o que igualmente demonstra que a droga era destinada para o comércio ilícito de entorpecentes.

Com vistas a se elucidar a questão relativa à pequena ou grande quantidade de drogas apreendidas, ensinam Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio que "a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,4 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente." (Moraes, Alexandre de Legislação Penal Especial, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, página 114)

Portanto, no caso em questão, considerando a quantidade de cocaína apreendida (145,81 gramas), seria possível o fracionamento em 364,52 porções individualizadas, número incompatível com a hipótese de consumo pessoal.

Desse modo, a quantidade relevante de droga encontrada (143,63 gramas), suficiente para confecção de diversas porções individuais; a apreensão de quantia em dinheiro (R\$ 20,00); o contexto da abordagem, com a tentativa de fuga do envolvido; bem como a confissão do acusado, infirmam a possibilidade de mera posse para consumo pessoal (Lei 11.343/06, art. 28, § 2º).

Saliente-se que, no tocante à "cocaína", a dose capaz de causar uma overdose seguida de parada cardíaca é de 0,2 a 1,5 gramas. Assim, como a quantidade de entorpecente encontrada em poder do acusado (145,81 gramas de massa líquida - laudo pericial de fls. 23/26) é bem superior à retro mencionada, não é crível que ele iria apenas usá-la.

De qualquer modo, oportuno ressaltar que o fato de uma pessoa ser usuária de drogas, por si só, não é suficiente para ensejar a desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que não há impedimento de que um usuário seja também traficante.

Observo que, ainda que os policiais não tenham visto o acusado efetivamente

entregando entorpecentes a usuários, tal circunstância em nada o socorre, já que o simples fato de trazer consigo e transportar a droga é suficiente para configurar o delito de tráfico de entorpecentes.

Guilherme de Souza Nucci, ao analisar o tipo previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, leciona que

Todas as condutas passam a ter, em conjunto, o complemento ainda que gratuitamente (sem cobrança ou valor). Logo, é indiferente haver ou não lucro, ou mesmo o intuito de lucro. Lembremos, ainda, que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito.

Por fim, o laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 88/102) concluiu que a droga apreendida continha o princípio ativo da substância entorpecente conhecida como "cocaína".

Assim, conforme o exposto há nos autos, elementos seguros que confirmam a materialidade e autoria do delito que recai sobre o acusado. A prova carreada aos autos é forte e coesa, não havendo que se falar em insuficiência de provas, nem em desclassificação do crime para o delito de consumo de drogas, sendo de rigor a condenação.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta do acusado, deve ser considerada normal. O acusado não ostenta antecedentes criminais (fls. 42). Sobre a conduta social e personalidade do acusado, não foram amealhados elementos suficientes nos autos para valorá-las, nos termos do decidido pelo STJ (HC 472.654 - DF, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019 - Informativo 643). Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. Ainda, em atenção ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, considerando que a natureza da droga apreendida (cocaína) é dotada de elevada capacidade de causar dependência física e psíquica, entendo que deve haver uma maior repressão por parte do Estado-Juiz. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Assim, a pena retorna ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento.

Por outro lado, é caso de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o acusado é primário e ostenta bons antecedentes, não havendo indicativos de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Registre-se que o acusado foi abordado na rodovia, na suposta condição de "mula", sem apreensão de nenhum apetrecho comumente utilizado na comercialização ilícita de entorpecentes (balança de precisão, invólucros plásticos, etc).

Demais disso, as testemunhas arroladas pela acusação afirmaram que o acusado não era conhecido dos meios policiais, inexistindo notícias de denúncias anônimas.

A defesa, por sua vez, trouxe testemunhas que afirmaram desconhecer a traficância habitual pelo acusado na cidade onde residia (Santa Fé do Sul).

Outrossim, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020) (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021).

Ou seja, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituam variáveis que podem sim ser consideradas para embasar conclusão de efetiva dedicação às atividades criminosas ou, até mesmo, de ser o imputado integrante de organização criminosa, contanto que outros elementos de prova constantes dos autos evidenciem tais condições, em conjunto com as mencionadas vetoriais (STJ, AgRg no HC n. 709.087/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022)

Ocorre que, no caso em questão, o órgão acusatório não logrou êxito em comprovar a efetiva participação do acusado no envolvimento de atividades criminosas ou mesmo de que ele integrava organização criminosa, de modo que, por ser primário e não ostentar maus antecedentes, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe.

Em relação ao quantum de diminuição, considerando que a quantidade de entorpecente apreendido era suficiente para inúmeras porções individuais, a pena deve ser diminuída pela metade (1/2), tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Ressalto é possível a menor redução da pena na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e/ou natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base, como é o caso em questão (STJ, HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).

O valor do dia-multa será de 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente a época dos fatos, pois não há, nos autos, informações sobre a real situação econômica do acusado que autorize fixá-lo acima desse patamar (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Esta magistrada sempre entendeu, em casos análogos de tráfico de drogas privilegiado, de que a pena privativa de liberdade deveria ser cumprida em regime fechado, por reputar ser mais adequado para os fins da pena.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em Habeas Corpus Coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, determinou "que não se imponha o regime inicial fechado aos acusados que vieram a serem sancionados pela prática do crime de tráfico privilegiado".

Eis a ementa do julgado:

(...)

18.3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores – quer por meio de súmulas (verbetes n. 718 e 719 do STF e 440 do STJ), quer por meio de julgamentos proferidos pela composição Plena do Supremo Tribunal Federal, seguidos por inúmeros outros julgamentos da mesma Corte e do STJ – é uníssona e consolidada no sentido de que:

18.3.1. Não se pode impor regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão



da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito e sem a idônea motivação, que não pode decorrer da mera opinião do julgador;

18.3.2. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33. § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial aberto ou, excepcionalmente, em semiaberto, desde que por motivação idônea, não decorrente da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do julgador;

18.3.3. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nas condições e nas ressalvas da alínea anterior, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

(...)

19. Essas são, portanto, as diretrizes que devem ser observadas – e normalmente o são, pela maioria de juízes e tribunais de todo o país –, por decorrerem de precedentes qualificados das Cortes Superiores (súmulas de jurisprudência, julgamentos pelo Tribunal Pleno do STF, recursos especiais julgados sob o rito dos recursos repetitivos do STJ, e extraordinários em repercussão geral, pelo STF), sobre questões jurídicas assentadas a partir da mesma situação fática, sempre ressalvada, naturalmente, a eventual indicação de peculiaridades do caso examinado, a permitir, mediante idônea e responsável motivação, distinguir a hipótese em julgamento da que fora decidida nos referidos precedentes.

20. Na espécie, a gravidade excepcional do delito não se sustenta, visto que o crime foi praticado em circunstâncias inerentes à caracterização da própria figura delitiva em apreço e, embora apreendidas cocaína e crack, a quantidade da droga, ao contrário do afirmado, não foi relevante (5,6 g no total).

21. Habeas Corpus concedido, para:

21.1. Em relação ao paciente individualizado na impetração, fixar o regime aberto como modo inicial de cumprimento da pena.

21.2. Em relação aos presos que, conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, se encontrem na mesma situação (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses, em regime fechado), fixar o regime aberto.

21.3. Em relação aos presos condenados, pelo delito de tráfico privilegiado, a penas menores do que 4 anos de reclusão – salvo os casos do item anterior – determinar que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a possibilidade de progressão ao regime aberto em face de eventual detração penal decorrente do período em que tenham permanecido presos cautelarmente.

21.4. Aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha – devendo haver pronta correção aos já sentenciados – o regime inicial fechado de cumprimento da pena.

Determinação para que se dê cumprimento desta ordem de Habeas Corpus, inclusive para que se providencie, junto aos respectivos juízes, a imediata expedição de alvarás de soltura aos presos que, beneficiados pelas medidas ora determinadas, não estejam presos por outros motivos

Assim, ressalvado o entendimento desta Magistrada, em obediência aos parâmetros

definidos pelo Superior Tribunal de Justiça e considerando que houve o reconhecimento do tráfico privilegiado, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'c', do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, e considerando que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, é caso de substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (art. 44, §2º, do CP), consistente a primeira no pagamento de 02 (dois) salários mínimos, revertido em favor de entidade assistencial a ser definida no juízo da execução e a segunda na limitação de final de semana, nos termos do artigo 44, §2º, 45, §2º, e 48, todos do Código Penal.

Face à substituição da pena privativa de liberdade, incabível se mostra a suspensão de sua execução (art. 77, inciso III, do Código Penal).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e, em consequência, CONDENO o acusado JUAN MANOEL CARLOS CELESTINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º, do Código Penal. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao acusado por duas penas restritivas de direito, sendo a primeira consistente no pagamento de 02 (dois) salários mínimos, a ser revertido em favor de entidade assistencial a ser definida no juízo da execução, e a segunda consistente na limitação de final de semana.

Considerando a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, REVOGO a prisão preventiva do acusado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, conforme artigo 387, parágrafo único, do mesmo diploma legal, salvo se por outro motivo estiver preso.

Expeça-se alvará de soltura, com urgência.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por entender que, no caso do delito tratado nos autos, incompatível tal estipulação.

Deixo, também, de aplicar o disposto no parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.736/12, tendo em vista a fixação do regime aberto.

Autorizo, desde já, a destruição dos entorpecentes que, eventualmente, tenha sido guardados para novos exames.

Não comprovada a utilização na prática do crime de tráfico de drogas, já que não realizado o desbloqueio pela perícia técnica (fls. 240/243), bem como considerando o arquivamento em relação ao investigado Kadmo, DETERMINO a restituição dos aparelhos celulares apreendidos, nos termos do artigo 60, §6º, da Lei 11.343/2006, oficiando-se à autoridade policial para as providências cabíveis.

No tocante ao dinheiro apreendido, considerando que o próprio acusado afirmou em solo policial de que era troco do combustível pago por terceiro para fazer o transporte do entorpecente (fls. 05), decreto o perdimento em favor do Estado, na forma do artigo 63 da Lei de Drogas.

Por outro lado, em relação à motocicleta apreendida, em que pese tenha sido utilizada para o transporte do entorpecente, observo que o bem pertence à instituição financeira em razão da existência de alienação fiduciária (fls. 301).

Desse modo, "não pode o credor fiduciário ver-se privado do bem de sua propriedade em razão de utilização em tráfico ilícito de entorpecentes, pois a perda do bem, prevista não apenas no Código Penal como também na Lei nº 11.343/2006, encontra exceção no direito de propriedade do terceiro de boa-fé". (TJSP; Agravo de Instrumento 9014015-06.2009.8.26.0000; Relator (a): Luís de Carvalho; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 02/09/2009; Data de Registro: 24/09/2009).

Assim, a motocicleta deverá ser restituída à instituição financeira credora, salvo se houver informação nos autos de quitação do contrato bancário, hipótese em que o bem será revertido em favor do Estado, na forma do artigo 63 da Lei de Drogas.

Neste ponto, convém mencionar que não foi reconhecida a posse legítima do pai do acusado, tendo em vista que o veículo foi apreendido em poder do réu por ocasião de sua prisão em flagrante delito por tráfico ilícito de entorpecentes.

Aliás, não raro veículos relacionados ao tráfico de drogas encontram-se registrados em nome de terceiros, inclusive parentes próximos, como no caso dos autos.

De mais a mais, conforme se observa nos autos n. 0000365-90.2022.8.26.0646, o pai do acusado nem sequer esclareceu de quem adquiriu a motocicleta ou juntou comprovante de pagamento, a fim de demonstrar a origem lícita do bem apreendido nestes autos.

Por fim, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o acusado ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, a título de taxa judiciária, observada eventual concessão da justiça gratuita.

Transitada em julgado, adotem-se as seguintes providências:

- 1) Expeça-se guia definitiva para o cumprimento da pena.
- 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- 3) Comunique-se ao IIRGD e proceda-se ao lançamento das informações pertinentes no Sistema Informatizado Oficial; e
- 4) Nos termos do Provimento CG 05/2022 (disponibilizado no DJE em 13/05/2022, p. 31), não havendo recolhimento de fiança no presente caso, consigno que o acusado deverá ser citado para pagamento da multa penal apenas no Juízo da Execução Penal, ficando dispensada a intimação pelo Juízo de Conhecimento.

P.I.C

Urania, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA